



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2004051 - SC (2022/0154564-5)

RELATORA : **MINISTRA LAURITA VAZ**
RECORRENTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OFENSA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRODUÇÃO UNILATERAL DE LAUDOS PERICIAIS PELA AUTORIDADE POLICIAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM CONHECIMENTO DO JUÍZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA. NULIDADE DOS EXAMES CONFIGURADA. JUNTADA NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS EXAMES NULOS. OFÍCIO DO DNIT. JUNTADA POSTERIOR À PRONÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA NESSE PONTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA EVIDENCIADOS. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR EXAME DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTOS E VÍDEOS. DIREÇÃO PERIGOSA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ESTABELECIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOLO EVENTUAL E FORMA TENTADA DO DELITO. INCOMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. *HABEAS CORPUS* CONCEDIDO, DE

OFÍCIO.

1. A análise da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais é inviável em recurso especial, destinada à uniformização da interpretação da lei federal.

2. É evidente a nulidade dos laudos periciais produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, quando já estava em curso a instrução criminal, e dos quais tomou conhecimento do Juízo quando já havia sido proferida a sentença de pronúncia, pois juntados aos autos tão-somente na fase em que a Defesa iria apresentar as razões ao seu recurso em sentido estrito dirigido contra a pronúncia.

3. Não houve controle judicial da produção das referidas perícias, e tampouco seguiram elas o regramento previsto no Código de Processo Penal, que inclui a nomeação do perito oficial ou compromissado, a possibilidade de indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, os quais são submetidos ao prévio exame judicial. Se cuida de ilegalidade na própria produção da prova. Devem tais perícias serem anuladas e desentranhadas dos autos.

4. A alegação de que também teria havido nulidade na juntada do "*Ofício nº 55223/2019, enviado pelo DNIT em decorrência de diligência realizada secretamente pelo MP*", após a pronúncia, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, sem que tenha sido objeto dos embargos de declaração defensivos. Carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal.

5. Constatação de ilegalidade manifesta nesse ponto, a ser reparada por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois a data em que foi assinado o referido Ofício é posterior à pronúncia, sendo ele juntado aos autos, a pedido do *Parquet* estadual, quando o feito estava em fase de recurso em sentido estrito. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa evidenciados, nos termos da fundamentação que levou ao reconhecimento da nulidade da juntada dos laudos periciais.

6. Os referidos laudos periciais, produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, bem como os dados constantes do Ofício n. 55223/2019, do DNIT, não foram utilizados pelo Magistrado singular para fundamentar a pronúncia, mesmo porque foram juntados aos autos em momento a ela posterior. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida na pronúncia, que não se fundamentou na prova produzida unilateralmente e não submetida ao contraditório.

7. O fato de que a pronúncia mencionou imagens que já constavam dos autos, mas que também acabaram por ser analisadas nos referidos exames unilaterais, não configura nulidade ou cerceamento de defesa. Haveria nulidade da pronúncia se as conclusões contidas nesse laudos tivessem lastreado a pronúncia, o que não foi o caso. Tampouco o acórdão confirmatório da pronúncia deles lançou mão para justificar a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri. As imagens já constavam dos autos antes da pronúncia, tendo sido colhidas ao longo da investigação policial e da instrução criminal.

8. Afirmaram as instâncias ordinárias que o Recorrente dirigia embriagado, segundo comprovado por exame de alcoolemia. E, ainda, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, conduzindo em zigue-zague pela rodovia e invadindo a contramão de direção, por várias vezes, em uma das quais ocorreu a colisão, conforme apurado por vídeos e depoimentos de testemunhas e vítimas sobreviventes. O conjunto dessas circunstâncias configura extrapolação do dever de cuidado, próprio do crime culposos, e constitui indício de dolo eventual, de maneira a justificar a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri.

9. Para rever as premissas fáticas apontadas como incontroversas no acórdão recorrido, bem assim verificar se haveria outros elementos probatórios que levariam a conclusão diversa, seria necessário o reexame de provas, o que se mostra inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

10. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmando no sentido de não haver incompatibilidade entre o dolo eventual e a forma tentada do delito de homicídio.

11. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes. Recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de anular os exames periciais realizados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e que foram juntados após a pronúncia, determinando que sejam desentranhados dos autos. *Habeas corpus* concedido, de ofício, para anular a prova produzida por meio da requisição de diligências feita pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT, determinando o desentranhamento do Ofício n. 55223/2019, do referido Órgão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade e conhecer parcialmente do recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, e, ainda, conceder habeas corpus, de ofício, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 15 de agosto de 2023.

Ministra LAURITA VAZ
Relatora

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2022/0154564-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.004.051 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00004292620208240000 00005492820198240025 00005895120208240000
00024668220198240025 24668220198240025 40059484520198240000
40102294420198240000 40108902320198240000 40171979020198240000
4292620208240000 5492820198240025 5895120208240000

PAUTA: 14/03/2023

JULGADO: 14/03/2023

Relatora

Exma. Sra. Ministra **LAURITA VAZ**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV. : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retirado de Pauta por indicação da Sra. Ministra Relatora.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA**

Número Registro: 2022/0154564-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.004.051 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00004292620208240000 00005492820198240025 00005895120208240000
00024668220198240025 24668220198240025 40059484520198240000
40102294420198240000 40108902320198240000 40171979020198240000
4292620208240000 5492820198240025 5895120208240000

PAUTA: 20/06/2023

JULGADO: 20/06/2023

RelatoraExma. Sra. Ministra **LAURITA VAZ**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV. : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV. : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado por indicação da Sra. Ministra Relatora para a sessão de 08.08.2023.

C542524515219-1129944@ 2022/0154564-5 - REsp 2004051



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2004051 - SC (2022/0154564-5)

RELATORA : **MINISTRA LAURITA VAZ**
RECORRENTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OFENSA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRODUÇÃO UNILATERAL DE LAUDOS PERICIAIS PELA AUTORIDADE POLICIAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM CONHECIMENTO DO JUÍZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA. NULIDADE DOS EXAMES CONFIGURADA. JUNTADA NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS EXAMES NULOS. OFÍCIO DO DNIT. JUNTADA POSTERIOR À PRONÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA NESSE PONTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA EVIDENCIADOS. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR EXAME DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTOS E VÍDEOS. DIREÇÃO PERIGOSA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ESTABELECIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOLO EVENTUAL E FORMA TENTADA DO DELITO. INCOMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. *HABEAS CORPUS* CONCEDIDO, DE

OFÍCIO.

1. A análise da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais é inviável em recurso especial, destinada à uniformização da interpretação da lei federal.

2. É evidente a nulidade dos laudos periciais produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, quando já estava em curso a instrução criminal, e dos quais tomou conhecimento do Juízo quando já havia sido proferida a sentença de pronúncia, pois juntados aos autos tão-somente na fase em que a Defesa iria apresentar as razões ao seu recurso em sentido estrito dirigido contra a pronúncia.

3. Não houve controle judicial da produção das referidas perícias, e tampouco seguiram elas o regramento previsto no Código de Processo Penal, que inclui a nomeação do perito oficial ou compromissado, a possibilidade de indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, os quais são submetidos ao prévio exame judicial. Se cuida de ilegalidade na própria produção da prova. Devem tais perícias serem anuladas e desentranhadas dos autos.

4. A alegação de que também teria havido nulidade na juntada do "*Ofício nº 55223/2019, enviado pelo DNIT em decorrência de diligência realizada secretamente pelo MP*", após a pronúncia, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, sem que tenha sido objeto dos embargos de declaração defensivos. Carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal.

5. Constatação de ilegalidade manifesta nesse ponto, a ser reparada por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois a data em que foi assinado o referido Ofício é posterior à pronúncia, sendo ele juntado aos autos, a pedido do *Parquet* estadual, quando o feito estava em fase de recurso em sentido estrito. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa evidenciados, nos termos da fundamentação que levou ao reconhecimento da nulidade da juntada dos laudos periciais.

6. Os referidos laudos periciais, produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, bem como os dados constantes do Ofício n. 55223/2019, do DNIT, não foram utilizados pelo Magistrado singular para fundamentar a pronúncia, mesmo porque foram juntados aos autos em momento a ela posterior. Assim, inexistente nulidade a ser reconhecida na pronúncia, que não se fundamentou na prova produzida unilateralmente e não submetida ao contraditório.

7. O fato de que a pronúncia mencionou imagens que já constavam dos autos, mas que também acabaram por ser analisadas nos referidos exames unilaterais, não configura nulidade ou cerceamento de defesa. Haveria nulidade da pronúncia se as conclusões contidas nesse laudo tivessem lastreado a pronúncia, o que não foi o caso. Tampouco o acórdão confirmatório da pronúncia deles lançou mão para justificar a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri. As imagens já constavam dos autos antes da pronúncia, tendo sido colhidas ao longo da investigação policial e da instrução criminal.

8. Afirmaram as instâncias ordinárias que o Recorrente dirigia embriagado, segundo comprovado por exame de alcoolemia. E, ainda, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, conduzindo em zigue-zague pela rodovia e invadindo a contramão de direção, por várias vezes, em uma das quais ocorreu a colisão, conforme apurado por vídeos e depoimentos de testemunhas e vítimas sobreviventes. O conjunto dessas circunstâncias configura extrapolação do dever de cuidado, próprio do crime culposos, e constitui indício de dolo eventual, de maneira a justificar a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri.

9. Para rever as premissas fáticas apontadas como incontroversas no acórdão recorrido, bem assim verificar se haveria outros elementos probatórios que levariam a conclusão diversa, seria necessário o reexame de provas, o que se mostra inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

10. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmando no sentido de não haver incompatibilidade entre o dolo eventual e a forma tentada do delito de homicídio.

11. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes. Recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de anular os exames periciais realizados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e que foram juntados após a pronúncia, determinando que sejam desentranhados dos autos. *Habeas corpus* concedido, de ofício, para anular a prova produzida por meio da requisição de diligências feita pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT, determinando o desentranhamento do Ofício n. 55223/2019, do referido Órgão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por EVANIO WYLYAN PRESTINI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição da República, contra acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos Autos n. 0002466-82.2019.8.24.0025.

O Ministério Público catarinense denunciou o Recorrente pela suposta prática dos crimes do art. 121, § 2.º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes, e do art. 121, § 2.º, incisos III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do referido Código, na forma do art. 70 do mesmo Estatuto e, ainda, em concurso material com o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Sobreveio sentença pronunciando o Recorrente como incurso no art. 121, *caput*, do Código Penal, por duas vezes, no art. 121, *caput*, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa opôs, sucessivamente, dois embargos de declaração, sendo ambos rejeitados. Houve recursos em sentido estrito defensivo e acusatório.

O recurso acusatório, que buscava a inclusão na pronúncia, da qualificadora do perigo comum, foi desprovido, em julgamento assim sintetizado (fl. 3181 - Apenso):

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, NA CONDUÇÃO, EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 121, CAPUT, POR DUAS VEZES; 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.507/97). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (INC. III DO § 2º DO ART. 121 DO CP). INVIABILIDADE. QUALIFICADORA INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DO DOLO EVENTUAL. PRECEDENTES.

'A circunstância de o delito haver sido praticado com o emprego de meio do qual tenha resultado perigo comum somente é imputável ao agente que age com dolo direto. Isso porque, quando o agente atua com dolo eventual ou de forma culposa, ele não desejou o resultado lesivo e, portanto, não possuía a específica intenção de criar um perigo comum' (STJ - REsp 1829587/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

RECURSO DESPROVIDO."

Esse acórdão transitou em julgado (certidão de fl. 3201- Apenso).

Por sua vez, o recurso em sentido estrito defensivo também foi desprovido, mas por

maioria, em acórdão assim ementado (fl. 1141):

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS E LESÕES CORPORAIS DOLOSOS NO TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS SEM PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. MANOBRAS PERIGOSAS E EXAME DE ALCOOLEMIA POSITIVO. DESPROVIMENTO."

A Defesa constituída opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso em sentido estrito, os quais foram rejeitados (fls. 1255-1261).

Após, interpôs recurso especial contra a parte unânime do referido acórdão (fls. 1316-1338). Nesse apelo nobre, trouxe o Recorrente a alegação de ofensa aos seguintes dispositivos:

a) arts. 5.º, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República e aos arts. 156, incisos I e II, 157 e 159, §§ 3.º, 4.º, e 5.º, 411 e 413 do Código de Processo Penal, pela falta de reconhecimento da *"nulidade das provas produzidas secretamente pelo Parquet, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa"* (fl. 1317). Argumenta que esses documentos (dois laudos periciais e um ofício requisitados pelo Ministério Público e pela autoridade policial durante a instrução) foram juntados aos autos tão-somente após a pronúncia, não obstante sua produção fosse a ela anterior;

b) arts. 18, inciso I, 121, *caput*, do Código Penal, arts. 302, § 3.º e 303, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal, pois não haveria elementos suficientes para demonstrar a presença do dolo eventual, sendo devida a desclassificação para o homicídio e lesões corporais culposas no trânsito.

Pediu o provimento do recurso especial, com a anulação do feito ou a desclassificação das condutas.

Interpostos embargos infringentes e de nulidade contra a parte não unânime do julgamento do recurso em sentido estrito, restaram desprovidos, por maioria, em acórdão com a seguinte ementa (fl. 1578):

"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). PRONÚNCIA PELOS CRIMES, EM TESE, DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, E DELITO CONEXO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 121, CAPUT, POR DUAS VEZES E 121, CAPUT, C/C 14, II, POR TRÊS VEZES, AMBOS NOS TERMOS DO ART. 18, II, IN FINE, TODOS DO CP E ART. 306 DO CTB). PRONÚNCIA MANTIDA APÓS JULGAMENTO COLEGIADO. DIVERGÊNCIA QUANTO A CONCILIAÇÃO ENTRE CATEGORIAS DOGMÁTICAS EM CRIME DE HOMICÍDIO. COMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- 'O DOLO EVENTUAL, NA PRÁTICA, NÃO É EXTRAÍDO DA MENTE DO AUTOR MAS, ISTO SIM, DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NELE, NÃO SE EXIGE QUE O RESULTADO SEJA ACEITO COMO TAL, O QUE SERIA ADEQUADO AO DOLO DIRETO, MAS ISTO SIM, QUE A ACEITAÇÃO SE MOSTRE NO PLANO DO POSSÍVEL, PROVÁVEL' (HC 503.796/RS, REL. MIN. LEOPOLDO DE

Seguiu-se a oposição de embargos de declaração defensivos, os quais foram rejeitados (fls. 1613-1614).

No recurso especial dirigido contra o acórdão dos embargos infringentes (fls. 1631-1653), a Defesa alega ofensa aos arts. 14, inciso II, 18, inciso I, e 121, *caput*, do Código Penal, ao argumento de que o dolo eventual seria incompatível com a forma tentada do delito de homicídio.

Pede o provimento do recurso especial com "*a desclassificação das três imputações de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais*" (fl. 1653).

Oferecidas contrarrazões (fls. 1668-1683 e 1685-1693). A Corte estadual não admitiu os recursos especiais (fls. 1719-1729 e 1737-1742), advindo agravos em recurso especial (fls. 1758-1825 e 1827-1851), contraminutados às fls. 1884-1888 e 1893-1898. A 2.^a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de retratação, acolheu o agravo e admitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito (fls. 1995-1997), mas manteve a inadmissão do apelo nobre manifestado contra o acórdão dos embargos infringentes e de nulidade (fl. 2000). Os autos subiram a esta Corte Superior.

O Ministério Público Federal, por meio do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso especial e pelo desprovimento do agravo em recurso especial, em parecer sintetizado na ementa que se segue (fl. 2021):

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. IMPROPRIEDADE DE DISCUSSÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA VIA ELEITA. JUNTADA DE PROVAS PELA ACUSAÇÃO APÓS A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. - Parecer pelo não conhecimento do recurso especial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. COMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM O CRIME TENTADO. SÚMULA 83/STJ. – Parecer pelo desprovimento do agravo."

Às fls. 2095-2096, atendendo a pedido da Defesa (fls. 2078-2092), requisitei a cópia integral dos autos da ação penal e seu apensamento a este recurso, tendo em vista que o Tribunal de origem havia encaminhado tão-somente o instrumento formado quando da interposição do recurso estrito defensivo.

Após a chegada dos autos principais, que foram devidamente apensados, deu-se nova vista dos autos ao Ministério Público Federal, que ratificou o seu anterior parecer (fl. 2107).

É o relatório.

VOTO

Como se verifica, consta dos autos dois recursos especiais interpostos pelo Recorrente. O primeiro, dirigido contra a parte unânime do acórdão proferido no recurso em sentido estrito, foi admitido pelo Tribunal de origem. O segundo, manifestado contra o julgamento proferido nos embargos infringentes e de nulidade, teve a sua admissão negada, com a interposição de agravo em recurso especial.

Procedo, inicialmente, à análise do recurso especial, manifestado contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, tendo em vista que o eventual acolhimento de alguma das alegações nele trazidas tornaria prejudicado o recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos embargos infringentes e de nulidade.

Pois bem, em primeiro lugar, constata-se que o referido recurso especial veiculou alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, o que se mostra inadequado para essa via recursal, destinada à uniformização da interpretação da lei federal.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, porque teria havido a juntada de documentos pela Acusação, após a interposição do recurso em sentido estrito, disse o Tribunal de origem (fls. 1127-1129; sem grifos no original):

"Segundo a defesa, a sentença de pronúncia seria nula em virtude da produção de provas, sobretudo periciais, na fase judicial, sem o seu conhecimento e a sua participação, ou seja, em desrespeito ao procedimento previsto nos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 159 do Código de Processo Penal e afronta ao princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia.

Não tem razão o recorrente, todavia.

De início, é preciso enfrentar a tese de inversão tumultuária de atos processuais, consubstanciada no fato de que o juízo a quo determinou a abertura de vista ao Ministério Público, após apresentadas alegações finais por todas as partes, para que ele se manifestasse sobre o Laudo Pericial n. 9100.19.1565, juntado aos autos antes das alegações finais do órgão de acusação.

Infere-se dos autos, a esse respeito, que o laudo pericial referido, apesar de ter sido juntado aos autos no dia 27 de maio de 2019, às 15:32 horas, foi recebido pelo órgão de acusação por meio eletrônico um pouco antes, às 15:13 horas do mesmo dia, e as alegações finais do Ministério Público, embora tenham sido disponibilizadas nos autos às 15:44 horas, foram assinadas no mesmo dia às 11:57 horas.

Assim, conclui-se que a acusação já havia finalizado e assinado suas alegações finais por volta de três horas antes de ter recebido o laudo pericial, motivo pelo qual a determinação do juízo para que lhe fosse dada nova vista não representou inversão tumultuária de atos processuais, como quer fazer crer a defesa.

Não bastasse isso, após a manifestação do Ministério Público sobre o Laudo Pericial n. 9100.19.1565, foi dada oportunidade tanto para o assistente de acusação quanto para a defesa se manifestarem sobre ele, chance que foi devidamente aproveitada pelo réu, como se infere da peça juntada às pp. 1347-1363.

Dito isso, quanto aos Laudos Periciais n. 9103.19.00083 (pp. 1580-1587) e n. 9102.19.1216 (pp. 1613-1619), ambos juntados aos autos após proferida a sentença de pronúncia (24 e 27 de junho de 2019), alega a defesa terem sido

secretamente requisitados, respectivamente, pela autoridade policial e pela acusação, de maneira que não teria sido garantida a participação da defesa na produção de tais provas, em ofensa ao procedimento previsto na lei processual penal (art. 159, §§ 3º, 4º e 5º, do CPP) e a princípios constitucionais (ampla defesa, contraditório, devido processo legal e isonomia).

Antes de mais nada, é preciso ressaltar que os laudos periciais 9103.19.00083 e 9102.19.1216, embora tenham sido realizados antes da sentença de pronúncia e juntados aos autos depois dela, não foram mencionados na referida decisão e, portanto, não serviram para fundamentá-la, de modo que nenhum prejuízo à defesa pode ser apontado até o momento em que foi dado o provimento jurisdicional aqui sob análise.

Ter o juízo a quo feito menção às gravações que posteriormente foram objeto de laudo pericial não gera nulidade da sentença de pronúncia, porquanto, como já referido, a perícia não foi mencionada, mas apenas as imagens que dela foram objeto.

A nulidade de tais laudos periciais é tema a ser abordado em momento oportuno, uma vez que, como já ficou evidente, tais provas técnicas não serviram de fundamento para a sentença de pronúncia nem eram, até o momento em que foi pronunciado o ora recorrente, conhecidas pelo juízo.

Abordar a legalidade da produção de tais provas, neste momento, representaria, inclusive, evidente supressão de instância, haja vista que tal tema ainda deve ser objeto de análise pelo juízo a quo, sobretudo porque se trata de procedimento composto em que, superada a fase de instrução preliminar ou de pronúncia, ainda há toda a preparação do processo para julgamento em plenário, em que há, inclusive, momento adequado para as 'diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa' (art. 423, I, CPP).

Assim, merece ser afastada a preliminar da sentença de pronúncia."

É evidente a nulidade dos laudos periciais produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, quando já estava em curso a instrução criminal, e dos quais tomou conhecimento do Juízo quando já havia sido proferida a sentença de pronúncia, pois juntados aos autos tão-somente na fase em que a Defesa iria apresentar as razões ao seu recurso em sentido estrito dirigido contra a pronúncia.

Registra-se que a denúncia foi oferecida em 06/03/2019 (fl. 396 - Apenso), e recebida na mesma data (fl. 468 - Apenso). A pronúncia foi proferida em 06/06/2019 (fls. 1896-1.892 - Apenso).

O pedido de juntada do laudo pericial produzido pela autoridade policial foi por ela protocolado em 25/06/2019, sendo o exame datado de 26/03/2019 (fls. 2105-2116 - Apenso). O Ministério Público, por sua vez, pediu a juntada do laudo produzido pelo Instituto Geral de Perícias em 27/06/2019 (fl. 2153), sendo o referido exame produzido entre 02 e 16/05/2019 (fls. 2158-2164). Portanto, a produção desses exames ocorreu de forma unilateral pela autoridade policial e pelo *Parquet* estadual, quando a ação penal já estava em curso, sendo as suas juntadas requeridas após a sentença de pronúncia.

Não houve controle judicial da produção das referidas perícias, e tampouco seguiram elas o regramento previsto no Código de Processo Penal, que inclui a nomeação do perito oficial ou compromissado, a possibilidade de indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, os quais são submetidos ao prévio exame judicial. Se cuida de ilegalidade na

própria produção da prova. Devem tais perícias serem anuladas e desentranhadas dos autos.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO E QUADRILHA. LAUDO DE CRIPTOANÁLISE PRODUZIDO POR PROFISSIONAL LIGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA ILÍCITA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Entende-se por perito oficial aquele investido no cargo criado por lei, caracterizando-se como auxiliar da justiça e submetendo-se, inclusive, às mesmas causas de suspeição e impedimento do magistrado.

2. Na hipótese vertente, conquanto o laudo pericial tenha sido elaborado por servidora pública, verifica-se que ela compunha o quadro de pessoal do Ministério Público Estadual, não atuando em órgão do Estado destinado exclusivamente à produção de perícias.

3. Assim, o exame questionado foi realizado, a pedido da Promotoria de Justiça que atua no feito, dentro da própria estrutura do Parquet, por meio do Grupo de Apoio Técnico Especializado, do qual a perita fazia parte, a despeito de qualquer ordem, autorização ou controle judicial.

4. O Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma imparcial no âmbito penal, de modo que é inconcebível admitir como prova técnica oficial um laudo que emanou exclusivamente de órgão que atua como parte acusadora no processo criminal, sem qualquer tipo de controle judicial ou de participação da defesa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A corroborar este entendimento, o artigo 276 do Código de Processo Penal é claro ao assentar a impossibilidade de interferência das partes no que diz respeito à indicação do perito.

6. O caso dos autos não comporta, ainda, a afirmação de que a perícia seria urgente, o que poderia legitimar a sua realização por técnica vinculada ao órgão de acusação, uma vez que se trata de perícia realizada no curso da ação penal, merecendo destaque o fato de que a agenda apreendida foi entregue à Delegacia de Polícia Fazendária sem que se requeresse ao magistrado responsável pelo feito a efetivação de qualquer exame técnico no documento.

7. Registre-se que a denúncia foi ofertada pelo órgão ministerial em 12.11.2007, recebida pelo Juízo em 13.03.2008, sendo que a agenda foi apreendida em poder do paciente em 28.11.2007, e a perícia reputada ilícita realizada em 19.04.2008.

8. Não há que se falar, portanto, em contraditório diferido, uma vez que, por óbvio, não se trata de perícia feita durante a fase policial - que sequer ocorreu no caso dos autos, já que a ação penal foi deflagrada a partir de procedimento investigatório conduzido pelo órgão ministerial -, tampouco de situação em que haveria urgência diante do risco de desaparecimento dos sinais do crime, ou pela impossibilidade ou dificuldade de conservação do material a ser examinado, pois, como visto, cuida-se de criptoanálise de uma agenda apreendida em poder de um dos acusados já no curso do processo criminal.

9. Restam prejudicadas as alegações segundo as quais haveria impedimento da técnica que elaborou o laudo em discussão, que também seria nulo porque realizado por apenas uma perita, uma vez que, conforme já ressaltado, não se tem, no caso vertente, perícia oficial.

10. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude do laudo pericial de criptoanálise realizado de forma unilateral pelo Ministério Público, determinando-se o seu desentranhamento dos autos." (HC n. 154.093/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 09/11/2010, DJe 15/04/2011; sem grifos no

original.)

A alegação de que também teria havido nulidade na juntada do "*Ofício nº 55223/2019, enviado pelo DNIT em decorrência de diligência realizada secretamente pelo MP*" (fl. 1331), após a pronúncia, não foi objeto de análise no acórdão recorrido, sem que tenha sido objeto dos embargos de declaração defensivos. Carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, constata-se ilegalidade manifesta nesse ponto, a ser reparada, de ofício, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois se constata, em relação a esse ponto, a mesma nulidade concernente à produção e juntada dos laudos periciais.

Com efeito, o referido Ofício teve por origem um pedido de esclarecimentos, para instrução da ação penal, feito pelo Ministério Público ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT, por meio de sua Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina. O referido Ofício foi datado de 24/06/2019 (fl. 2155), sendo a sua juntada aos autos requerida, pelo *Parquet* estadual, em 27/06/2019, na mesma petição em que requereu fosse juntado o laudo pericial produzido pelo Instituto Geral de Perícias (fl. 2153). Nítida, portanto, a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Os referidos laudos periciais, produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, bem como os dados constantes do Ofício n. 55223/2019, do DNIT, não foram utilizados pelo Magistrado singular para fundamentar a pronúncia, mesmo porque foram juntados aos autos em momento a ela posterior. Assim, inexistente nulidade a ser reconhecida na pronúncia, que não se fundamentou na prova produzida unilateralmente e não submetida ao contraditório.

No entanto, a produção desses exames e a sua juntada posterior à pronúncia, não teve o condão de nulificar esta decisão.

O fato de que a pronúncia mencionou imagens que já constavam dos autos, mas que também acabaram por ser analisadas nos referidos exames unilaterais, não configura nulidade ou cerceamento de defesa. Haveria nulidade da pronúncia se as conclusões contidas nesse laudo tivessem lastreado a pronúncia, o que não foi o caso. Tampouco o acórdão confirmatório da pronúncia deles lançou mão para justificar a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri. As imagens já constavam dos autos antes da pronúncia, tendo sido colhidas ao longo da investigação policial e da instrução criminal.

Em relação à conclusão no sentido da presença de indícios de dolo eventual e de inviabilidade de desclassificação, na fase de pronúncia, para a forma culposa dos delitos, disse a pronúncia (fls. 2048-2057; sem grifos no original):

"A versão da dinâmica do acidente contada pelas vítimas Thainara Schwartz e Maria Eduarda Kraemer e pela testemunha Tiago de Almeida, diverge frontalmente daquela exposta, acima, pelos testigos Patrício Eduardo Llanos Cerda, Ventura Raphael Martello Filho e Claito Jair Cani, pois afirmam que o acusado foi

o responsável pela colisão (mídia de fls. 926/927 e 1039).

Maria Eduarda Kraemer, vítima que se encontrava no banco traseiro do veículo do Fiat/Pálio Fire Flex, relatou, que, antes do abalroamento estava juntamente com Amanda, Suelen, Thayná e Thainara em uma festa, no estabelecimento chamado 'Galeras', em Itajaí. Disse que Thainara não fez uso de bebida alcoólica, pois já estava combinado que ela voltaria dirigindo, pois era a motorista da rodada. Em relação à disposição em que elas estavam no veículo quando do retorno da festa, disse que Thainara estava dirigindo, Suelen ao lado da motorista, a depoente estava no banco de trás - no meio, Thayná a sua esquerda e Amanda a sua direita. Não se recorda se utilizava cinto de segurança, mas lembra que a motorista e Suelen faziam uso do cinto. **Quanto ao acidente, relatou que o dia já estava claro e, um pouco antes do impacto, viu o acusado invadir a pista de rolamento em que elas transitavam, vindo em direção ao Pálio de forma muito rápida.** Lembra que estavam todas acordadas e que Thainara tentou jogar o carro para a outra pista, já que ali não havia acostamento em razão de obras de duplicação, quando ocorreu a colisão. Afirmou que estavam muito devagar e acredita que Thainara reduziu ainda mais a velocidade e desviou o carro para o lado, tentando evitar o veículo que vinha em sentido contrário. Reprisa que foi tudo muito rápido, não sabendo dizer detalhes sobre o acidente. Em decorrência do acidente, quebrou a bacia em quatro lugares, estourou a bexiga, quebrou o nariz e teve um corte na testa. Está fazendo fisioterapia e tratamento psicológico e ainda não consegue andar, estando em cadeira de rodas. (mídia de fls. 926/927).

A vítima Thainara Schwartz, motorista do veículo Fiat/Pálio Fire Flex, placas-MKI5640, confirmou que estava juntamente com as outras ofendidas em uma festa no 'Galeras', em Itajaí, ocasião em que não ingeriu bebida alcoólica ou substância entorpecente, pois haviam combinado que ela dirigiria o carro naquela noite. Sobre o acidente disse que, ao retornarem para Blumenau, trafegava em uma velocidade de setenta quilômetros por hora, quando avistou o acusado conduzindo veículo em alta velocidade, na mesma mão de direção em que a depoente. **Nesse momento, recorda-se que deu uma leve freada para ver se o condutor voltaria para a pista dele, e quando viu que isso não ocorreu jogou seu carro para a pista contrária (pista da esquerda sentido Blumenau/litoral), para desviá-lo. Afirma que, antes de desviar, olhou e não viu ninguém vindo atrás do Jaguar e por este motivou jogou para a pista da esquerda, aquela que era para ser a dele, na tentativa de salvar a vida de todas.** Explica que como trabalha na área da saúde, possui algumas noções básicas sobre socorros. Assim, consumado o sinistro, foi até Suelen, colocou o dedo no seu pescoço e não sentiu mais batimentos cardíacos; ao abrir seus olhos, notou que a pupila estava dilatada. Dirigiu-se, então, à Amanda, percebeu que o seu abdômen estava mexendo e concluiu que ainda estava viva.

Thayná estava aparentemente acordando e a depoente então pediu para que ficasse deitada. Em seguida, foi até Maria, colocou a mão em seu rosto e disse: 'a culpa não foi minha', quando ela desmaiou. Como não acreditava que Suelen estava morta, retornou a ela e começou a bater em seu rosto, dizendo 'acorda, acorda'. Com o impacto, contou que ficou lesionada no peito, em razão do cinto de segurança, tendo sua boca e coxa bem machucadas. Ficou duas semanas sem trabalhar, por conta das lesões. Está fazendo tratamento psicológico para superar o trauma do acidente (mídia de fls. 926/927).

Tiago de Almeida disse ser motorista de ônibus da empresa Gadoti e ter presenciado o acidente. Afirmou que pegou a BR-470, uns cinco quilômetros antes de chegar na 'Churrascaria Tôni', quando então passou a trafegar atrás do veículo das vítimas, a uma velocidade que não ultrapassava setenta e cinco quilômetros por hora. Metros antes do acidente, existe uma curva à esquerda e o depoente viu o veículo branco vindo, já perdido no acostamento da via de tráfego dele, ao desviar de um trator do tipo 'tobata' que ali transitava, e quando o acusado retornou para a pista já o fez na faixa da esquerda (na contramão de direção dele e na mão de direção do depoente e das vítimas). Acrescentou que foi tudo muito rápido, mas conseguiu parar o ônibus e presenciar a colisão. Especificamente sobre a dinâmica

do acidente e os fatos subsequentes disse: a motorista do Pálio segurou (freou) o veículo, como em um ato de tentar entender o que estava acontecendo, e, quando viu que não teria outra saída, a condutora puxou o carro para a esquerda, momento em que houve a colisão. Relatou que foi a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Em seguida, foi em direção ao veículo das vítimas e ajudou a motorista do Pálio a sair do carro, inclusive a ajudou a tirar o cinto de segurança, pois ela não encontrava o botão para destravá-lo. Deu a volta no carro e foi ver a vítima Suelen, que percebeu, pelo pouco que entende, que já estava sem vida. Em seguida, passou para a vítima de trás, que era a Amanda, que naquele momento ainda falava alguma coisa. O depoente então perguntou para ela o seu nome e esta não respondeu, quando então o declarante segurou a mão dela e ela disse que não queria morrer sozinha, que estava com medo, que não era para deixar ela morrer sozinha, que era para avisar à sua família. Aos poucos, Amanda foi soltando a mão do depoente. Este acreditou que ela tinha falecido, mas depois ficou sabendo que morreu no hospital. Novamente circundou o carro e viu a vítima Maria Eduarda, que gritava muito, tendo o depoente ficado com ela até a chegada do resgate, quando então os bombeiros o tiraram daquela área e isolaram o local. Recordou-se que entre o seu telefonema de chamada aos bombeiros e a chegada deles no local, demorou cerca de dez minutos. Dirigiu-se então para o veículo Jaguar capotado, na tentativa de tentar entender o que estava acontecendo, uma vez que até então não sabia quem estava naquele carro e se existiam mais pessoas feridas dentro dele.

Nesse momento, já havia chegado bastante gente no local e o acusado se encontrava ali. Lembra-se que o veículo Jaguar estava de cabeça para baixo e a porta do motorista aberta, em direção ao asfalto. Na hora, Evanio estava sentado na porta do bagageiro, com algumas garrafas na mão, tentando esconder essas garrafas aparentemente de bebidas alcoólicas, pois os frascos eram transparentes, não sabendo precisar a marca, mas se recorda que tinham o rótulo vermelho, podendo ser Bacardi ou Smirnoff. Além das garrafas, também havia copos. O acusado se levantou, quando então o depoente percebeu que ele estava embriagado, pois era visível este estado alcoólico, já que quase não se aguentava em pé e exalava cheiro de bebida alcoólica quando falava. O depoente pediu para que o motorista o acompanhasse para mostrar a ele o que fez: passou por debaixo do cordão de isolamento e mostrou para o acusado a situação do acidente, chamando a sua atenção para o ocorrido. O depoente mostrou para os bombeiros o acusado e pediu para que eles dessem atenção especial, para evitar eventual fuga.

Novamente foi retirado daquela área. O depoente ficou mais um pouco assistindo ao resgate de longe, tendo depois saído do local (mídia de fl. 1039).

Thayná Carolina Círico, vítima que se encontrava no banco traseiro do veículo do Fiat/Pálio, confirmou que foi junto com Thainara, Suelen, Maria Eduarda e Amanda em uma festa em um clube fechado, próximo ao Warung. No evento, a depoente, Suelen e Duda dividiram um litro de whisky, mas Thainara não ingeriu bebida alcoólica, apenas água, pois foi dirigindo o próprio carro e era 'a motorista da rodada'. Sobre o acidente, disse que não se recorda dos fatos, lembrando somente do que aconteceu até o momento que saíram da festa. Lembra de quando entraram no carro, Thainara estava dirigindo, Suelen ao lado dela e no banco de trás, a depoente estava sentada atrás da Thainara, Maria Eduarda no meio e a Amanda ao lado de Maria Eduarda. Após isso, lembra que acordou quando ganhou alta no hospital, ocasião em que o médico lhe contou o que tinha acontecido, pois até ali não sabia de nada e não sabia o motivo pelo qual estava no hospital. Em razão da colisão, ficou com a perna roxa e o braço bem inchado, ficando um mês sem poder movimentar o braço direito. Permaneceu aproximadamente duas semanas sem trabalhar e faz tratamento psicológico, por conta do acidente.

[...]

Denis Henrique Neves de Freitas, Policial Rodoviário Federal, relatou que chegaram no local do acidente, aproximadamente um hora após os fatos, pois

demoraram para comunicá-los, constatou que somente a vítima motorista estava ali, pois as demais vítimas já tinham sido encaminhadas para os hospitais. Foi realizado o teste do bafômetro nos dois condutores, mas somente Evanio teve resultado positivo para álcool. Além do exame de alcoolemia, o depoente percebeu que o acusado apresentava sinais de embriaguez: exalava forte odor etílico e estava com andar desequilibrado. Contudo, não tem conhecimento de que a Polícia Rodoviária Federal tenha recebido anteriormente algum telefonema de que o acusado transitava com o veículo Jaguar de forma irregular. Sobre o acidente, afirmou que lavrou o boletim de ocorrência com base nos vestígios que encontrou no local, mas não foi possível constatar qual a velocidade que cada veículo transitava no momento anterior à colisão. Ressaltou que em razão dos vestígios pós-colisão, é possível afirmar que o veículo Jaguar trafegava na contramão de direção. Afirmou que não tinham marcas de frenagem no local. Apenas marcas de fricção pós-impacto, tendo concluído que o ponto de impacto foi na pista de quem vinha de Blumenau para o litoral, em razão da concentração dos fragmentos da batida, pois a maior concentração é o ponto de colisão. Afirmou que no local do acidente a condutora do veículo Pálio não tinha a opção de manobrar o seu veículo para o lado direito, já que ali está acontecendo a obra de duplicação que retirou o acostamento da mão de direção da vítima (mídia de fl. 1011).

Conforme já destacado anteriormente, em sede de pronúncia há uma inversão da regra procedimental comum do in dubio pro reo para o chamado in dubio pro societate. Assim, somente diante de uma prova inequívoca excludente de ilicitude ou da demonstração cabal da inexistência do crime, é que pode o acusado ser subtraído do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos, pois há elementos indiciários aptos a sustentar a admissibilidade da denúncia.

Existem indícios suficientes para esta fase procedimental, de que o réu estava dirigindo veículo automotor sob o efeito de álcool, conforme se verifica no documento de fl. 25, que atesta a concentração de 0,72 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões do acusado, logo após os fatos, e do depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal, Denis Henrique Neves de Freitas, que, em juízo, relatou ter constatado sinais de embriaguez em Evanio (forte odor etílico e andar desequilibrado - mídia de fl. 1011 - 04'03" a 04'16").

Em continuidade de análise, há elementos de prova de que o acusado trafegava seu veículo de forma irregular pela BR-470. Além do vídeo de fls. 26/27, por meio do qual é possível perceber o acusado ziguezagueando na pista da referida rodovia, há o depoimento das testemunhas Silvio Bambinetti e Mônica Hoppe Bambinetti que efetuaram a gravação das imagens.

Silvio Bambinetti afirmou que trafegava sentido Rio do Sul - Litoral, quando, por volta de cinco horas, em Apiúna, encontrou com o Jaguar, que transitava em sua frente, tendo percebido que aquele condutor não estava em estado normal, acreditando que se encontrava bêbado. Disse que não presenciou o motorista réu ultrapassar qualquer veículo, no entanto ele ziguezagueava pelo asfalto e variava do acostamento à pista contrária de sua mão de direção. Em razão disso, o depoente buzinou e deu sinal de luz, na tentativa de fazê-lo parar, porém o que o acusado mais fazia era aumentar e diminuir a velocidade – quarenta/cinquenta quilômetros por hora a cem quilômetros por hora. No percurso que o acompanhou, cerca de vinte e dois quilômetros, o depoente viu o acusado ziguezaguear por três vezes, no total. Para o acostamento, ele foi por duas vezes, e, por três vezes, invadiu a pista contrária na contramão de direção. Quase colidiu com um motoqueiro, que passou bem próximo do canto da ponte em Ascurra para desviar e, na contramão, quase bateu com um caminhão, que foi para o acostamento; a última vez que o acusado ziguezagueou está estampada na imagem que aparece no vídeo (mídia de fl. 993).

Mônica Hoppe Bambinetti confirmou o depoimento prestado por seu marido Silvio, enfatizando que o acusado, por muitas vezes, ziguezagueou na pista: ora trafegava com o carro inteiro no acostamento, ora invadia a pista contrária. Quase colidiu com um caminhão, que, para desviar, 'tirou' para o lado

direito. Também quase colidiu com um motoqueiro em uma reta. (mídia de fl. 993).

Há nos autos imagens gravadas por uma câmera de segurança de uma empresa - que dista cem metros do local dos fatos, as quais não descartam que o acusado estaria trafegando o seu veículo, momentos antes do impacto, também na pista de rolamento contrária a sua mão de direção e, aparentemente, em alta velocidade (mídia de fl. 637, analisadas em sequência), o que sugere conformidade com o laudo mecânico complementar de fls. 1097/1102.

A prova produzida até o presente momento não demonstra, com a certeza que aponta a defesa, que o acidente que retirou a vida de Suelen e Amanda e quase ocasionou a morte de Thainara, Thayná e Maria Eduarda, ocorreu exclusivamente em razão de conduta da motorista do veículo Pálio Fiat/Pálio Fire Flex, placa-MKI5640. Também não há elementos para excluir as aludidas embriaguez, alta velocidade e direção irregular do réu nesta fase.

Portanto, a tese de que o acusado não foi o responsável pelo acidente, defendida no bojo das alegações finais da defesa, não pode ser acolhida nesta fase procedimental, pois não é dado ao juiz singular a faculdade de se aprofundar nas provas produzidas, sob pena de usurpar a competência do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida – o júri popular.

A defesa requereu a desclassificação dos delitos contra a vida para aqueles previstos nos arts. 302, § 3.º e 303, do Código de Trânsito Brasileiro, os quais se referem às práticas de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool e lesão corporal culposa.

Contudo, até o presente momento, os elementos de prova indicam que a conduta praticada pelo acusado, para este juízo de admissibilidade, deve ser inserida na modalidade do dolo eventual, mantendo-se a capitulação das infrações apuradas no art. 121, do Código Penal, nas modalidades consumada e tentada.

Como sabido, a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente está, no primeiro caso, em o agente, ao praticar a conduta, prever o resultado e não se importar com que este ocorra – assumindo o risco de causá-lo, e, no segundo, acreditar piamente que este resultado não ocorrerá.

[...] contrapõem a versão do acusado e apontam que o réu, em tese, após a ingestão de bebida alcoólica, teria dirigido o veículo Jaguar em vários trechos da BR- 470 de forma irregular, ziguezagueando pela pista (mídias de fls. 26-27 e depoimentos testemunhais). Momentos antes do acidente, aparentemente em alta velocidade, teria transitado pela pista de rolamento contrária (mídias de fl. 637 ch05_20190223061407 e ch05_20190223061436 quando analisadas em sequência). Há laudo nos autos aferindo que o acusado se encontrava em limite superior ao permitido para o trecho em que ocorreu a colisão, pois trafegava a 111,03 km/h nos cinco segundos que antecederam ao abalroamento, 102,15 km/h meio segundo antes da batida e 92,30 km/h no momento do impacto (fls. 1097/1102).

O conjunto dessas situações são indícios de que o réu aceitou o resultado de causar a morte das vítimas e justificam que, neste juízo de cognição, a conduta seja tipificada no art. 121 do Código Penal, na modalidade tentada em relação às vítimas Thainara, Thayná e Maria Eduarda e na modalidade consumada quanto as vítimas Suelen e Amanda.

Não é demais lembrar que nesta fase, a dúvida sobre o animus que movia Evanio Wylyan Prestini no momento do evento delituoso, impõe a necessidade de pronúncia, especialmente quando o quadro fático presente nos autos é apto a indicar que o acusado assumiu esse risco de produzir o resultado morte."

A Corte estadual, por sua vez, confirmou a pronúncia nos seguintes termos (fls. 1129-1135; sem grifos no original):

"Segundo a defesa, os dois fatos tidos como homicídios dolosos consumados

e os três tidos como homicídios dolosos tentados devem ser desclassificados, respectivamente, para homicídios culposos e lesões corporais culposas no trânsito.

Cabe ressaltar, de início, que toda a argumentação relativa à festa em que estavam as vítimas, antes dos fatos aqui apurados, com intuito de desqualificar a versão narrada na denúncia, segundo a qual foi o ora recorrente o responsável pelo acidente de trânsito, não tem o condão de impedir a pronúncia.

Dessa maneira, o contexto da festa em que estavam as vítimas – se lá havia ou não consumo de drogas e álcool – não afasta, de plano, a versão de que o ora recorrente dirigia perigosamente e sob o efeito de bebida alcoólica, dada pelas próprias vítimas sobreviventes (p. 926-927) e por Tiago de Almeida (p. 1039), motorista da empresa Gadotti que vinha logo atrás do veículo delas.

É que não há prova cabal de que a motorista do Fiat/Palio estivesse dirigindo sob o efeito de álcool ou alguma substância ilícita e, mesmo que houvesse, ela não excluiria de plano a responsabilidade do pronunciado.

Em relação ao depoimento de Tiago de Almeida (p. 1039), que disse ter visualizado o acidente, não é possível afirmar, com a certeza que exige eventual sentença de impronúncia, que ele tenha mentido ao narrar que testemunhou as manobras arriscadas do acusado.

Novamente, acolher as alegações da defesa, neste momento processual, sobretudo quando existe outra versão plausível nos autos, violaria a soberania do Tribunal do Júri.

É que, sabe-se, a fase de pronúncia não exige certeza e, portanto, na hipótese de existirem versões conflitantes dos fatos, é o Tribunal do Júri o único soberano para decidir qual delas deve prevalecer.

[...] inviável acolher, por ora, a tese de que o recorrente agiu com culpa e não com dolo, isso porque há elementos suficientes a indicar que ele dirigia alcoolizado e de modo irresponsável, de forma que é plenamente plausível a versão de que assumiu o risco de eventualmente causar mortes ou lesões corporais no trânsito.

Há indícios – como o exame de alcoolemia, alguns vídeos (pp. 191, 567 e 993) bem como os depoimentos das vítimas sobreviventes (p. 926-927) e de Tiago de Almeida (p. 1039) – dando conta de que o acusado dirigia alcoolizado e efetuava manobras perigosas, inclusive com invasão da mão contrária de direção, de maneira a tornar aceitável a versão narrada na inicial de que ele teria assumido o risco de causar as mortes e as lesões corporais.

É bom ressaltar que a defesa trouxe aos autos julgados em que se procede a desclassificação de delitos dolosos para culposos, porém nenhuma das hipóteses trazidas considera o fato de o acusado estar alcoolizado e dirigindo de maneira irresponsável, tal como indicam os elementos carreados a estes autos.

De qualquer forma, só o Tribunal do Júri tem soberania para, na presença de versões conflitantes nos autos, decidir a respeito da presença da culpa ou do dolo eventual, com o fim de avaliar a possibilidade de desclassificação dos fatos, sobretudo quando existem elementos suficientes a apontar para as formas dolosas dos delitos

[...]

Assim, uma vez que a materialidade do delito ficou amplamente comprovada e que a autoria sequer foi negada, embora a defesa sustente a tese de que as vítimas vinham de uma festa onde havia consumo de drogas e álcool, de maneira a sugerir que a condutora Thaynara dera causa ao acidente, estão presentes os elementos necessários à pronúncia do ora recorrente.

De igual forma, existem vídeos e depoimentos que formam indício suficiente de que o réu agiu com dolo eventual, porquanto dirigia perigosamente (depoimento de p. 1039 e vídeos de p. 993) e bastante alcoolizado (p. 25).

Diante da soberania do Tribunal do Júri, não cabe neste momento processual, é de se repetir, analisar detalhadamente as provas, como pretende a defesa que este órgão jurisdicional faça, haja vista as dezenas de páginas em que menciona cada detalhe dos fatos.

O importante, aqui, é ter-se em mente que existem indícios bastante contundentes de que o pronunciado deu causa ao acidente e assumiu o risco de produzir os resultados que efetivamente foram constatados, porquanto, mesmo embriagado, assumiu a direção de veículo automotor e, mais do que isso, há elementos a indicar que estava em velocidade superior à permitida no local, realizava manobras perigosas e dirigia em zigue-zague, a ponto de invadir a pista contrária, tudo isso em via (BR-470), como é público e notório, de tráfego intenso e que, por isso, oferece grande risco aos que por lá transitam.

Esses fatos são indicativos de que assumiu o risco do resultado, ou seja, agiu com dolo eventual, de modo que é o Conselho de Sentença que deve dirimir a dúvida entre as versões da defesa e da acusação.

Por fim, em evidente, aí sim, inversão tumultuária da ordem processual, em momento totalmente inadequado, posterior às contrarrazões a ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrente vem aos autos para juntar petição em que traz novos pedidos e elementos de prova, com o intuito de obter habeas corpus de ofício em seu benefício (pp. 375-387), com o intuito de ver anuladas provas que considera terem sido secretamente produzidas pela acusação.

Em síntese, alega que foi iniciado inquérito policial para apurar eventual prática de falso testemunho contra Tiago de Almeida, que foi realizada análise por assistente técnico dando conta de que o réu não trafegava na contramão e que o exame de bafômetro, segundo perícia particular, contém inconsistências capazes de invalidá-lo, fatos que, segundo a defesa, demonstram as ilegalidades passíveis de serem declaradas nulas pela via do habeas corpus de ofício.

Ora, além de o momento processual ser inadequado, não custa ressaltar que a existência de inquérito policial para investigar a prática de crime de falso testemunho por Tiago de Almeida, por ainda não ter havido sequer o oferecimento de denúncia, em nada altera a situação destes autos.

Já em relação às perícias realizadas para comprovar que o réu não estava na contramão e que o teste de bafômetro contém inconsistências, tem-se que elas, antes de mais nada, deverão ser analisadas pelo primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, incabível a concessão de habeas corpus de ofício e, também, inadmissível a juntada de 'contraprovas'."

Afirmaram as instâncias ordinárias que o Recorrente dirigia embriagado, segundo comprovado por exame de alcoolemia. E, ainda, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, conduzindo em zigue-zague pela rodovia e invadindo a contramão de direção, por várias vezes, em uma das quais ocorreu a colisão, conforme apurado por vídeos e depoimentos de testemunhas e vítimas sobreviventes. O conjunto dessas circunstâncias configura extrapolação do dever de cuidado, próprio do crime culposos, e constitui indício de dolo eventual, de maneira a justificar a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o

automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja lesionado.

3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora assuma o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem jurídico tutelado.

5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia." (REsp n. 1.922.058/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade haver o paciente agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados.

3. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual' (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes.

5. Habeas corpus parcialmente concedido para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP." (HC n. 590.002/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 11/10/2021; sem grifos no original.)

Para rever as premissas fáticas apontadas como incontroversas no acórdão recorrido, bem assim verificar se haveria outros elementos probatórios que levariam a conclusão diversa, seria necessário o reexame de provas, o que se mostra inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise do agravo em recurso especial dirigido contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade, e constatando que estão preenchidos os pressupostos para o conhecimento do referido agravo, prossigo na análise do apelo nobre.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmando no sentido de não haver incompatibilidade entre o dolo eventual e a forma tentada do delito de homicídio.

A esse respeito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO, CONSUMADO E TENTADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA COMPATÍVEIS, EM TESE, COM A ASSUNÇÃO DO RESULTADO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

- Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 656.689/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021; sem grifos no original.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PERDA DE OBJETO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. 'Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte' (HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido, é o AgRg no REsp 1.322.788/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015.

4. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a legislação processual pertinente, mantenho-a incólume.

5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 120.591/BA, Rel.

Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020; sem grifos no original.)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de anular os exames periciais realizados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e que foram juntados após a pronúncia, determinando que sejam desentranhados dos autos. CONCEDO *habeas corpus* , de ofício, para anular a prova produzida por meio da requisição de diligências feita Ministério Público do Estado de Santa Catarina ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT, determinando o desentranhamento do Ofício n. 55223/2019, do referido Órgão.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA**

Número Registro: 2022/0154564-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.004.051 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00004292620208240000 00005492820198240025 00005895120208240000
00024668220198240025 24668220198240025 40059484520198240000
40102294420198240000 40108902320198240000 40171979020198240000
4292620208240000 5492820198240025 5895120208240000

PAUTA: 20/06/2023

JULGADO: 15/08/2023

RelatoraExma. Sra. Ministra **LAURITA VAZ**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV. : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : EVANIO WYLYAN PRESTINI
ADVOGADOS : GILMAR KRUTZSCH - SC006568
ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
SOC. de ADV. : BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
PORCIÚNCULA ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. FERNANDO DA SILVA COMIN, pela parte RECORRIDA/AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Dr. ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES, pela parte RECORRENTE/AGRAVANTE: EVANIO WYLYAN PRESTINI

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade e conheceu parcialmente do recurso especial dirigido contra o acórdão proferido

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA**

Número Registro: 2022/0154564-5

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.004.051 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

no Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, e, ainda, concedeu habeas corpus, de ofício, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C542524515219:11129944@ 2022/0154564-5 - REsp 2004051